

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश

०७९-WO-०४३३

भिम बहादुर कार्कीको नातिनी, पदम बहादुर कार्कीको छोरी, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. १८ बस्ने ललितपुर जिल्ला, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. ३, प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्की..... १

निवेदक

विरुद्ध

निर्वाचन आयोग, काठमाडौं..... १

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ललितपुर जिल्ला, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३, ललितपुर..... १

प्रत्यर्थी

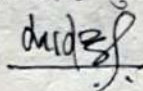
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, काठमाडौं..... १

मुद्दा:-उत्प्रेषण समेत।

नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा:

१. म निवेदक चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न एक नेपाली नागरिक हुँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि ललितपुर जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कागजात संलग्न गरी मिति २०७९/०६/२३ मा विपक्षी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता गरेको थिएँ। उम्मेदवारको योग्यताका सम्बन्धमा उजुरी दिने तोकिएको समयमा मेरो उम्मेदवारीविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन र विपक्षी निर्वाचन



दादा

अधिकृतको कार्यालयले मिति २०७९/०६/२६ मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी मलाई "गोलाकार भित्र घण्टी" निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेको थियो।

यसरी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भई निर्वाचन चिन्ह प्रदान भइसकेपछि म निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न रहेको अवस्थामा मिति २०७९/०७/०२ मा विपक्षी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा म प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भनी उजुरी परेको रहेछ। सो सम्बन्धमा विपक्षी मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मिति २०७९/०७/०३ मा स्पष्टीकरण माग गरेकोमा मैले मिति २०७९/०७/०६ मा आफू प्रचलित कानून बमोजिम पूर्ण रूपमा योग्य रहेको व्यहोरा खुलाउँदै स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ। तर विपक्षी निर्वाचन आयोगले एकतर्फी रूपमा कारवाही गरी मिति २०७९/०७/१२ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट निर्वाचित सदस्यको पद धारण गरेको कारण म "लाभको पदमा बहाल रहेको" भनी ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(ड) तथा दफा १५(५) बमोजिम मेरो उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय गरेको रहेछ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(ड) अनुसार उम्मेदवार हुनका लागि "कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको" हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाको स्पष्टीकरणमा "लाभको पद" भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदलाई बुझिने स्पष्ट गरिएको छ।

म नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ४(च) बमोजिम दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा चयन हुने सदस्य हुँ। उक्त पद कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने पद होइन। काउन्सिलको सदस्यले नियमित तलब, भत्ता वा आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्दैनन्। बैठकमा उपस्थित हुँदा दिइने बैठक भत्ता वा अनुगमनमा जाँदा दिइने भत्ता पद धारण गरेबापत प्राप्त हुने नियमित पारिश्रमिक नभई आवतजावत खर्चको सोधभर्ना मात्र हो।

यसैगरी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि म बहालमा रहेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्यापक पदबाट राजीनामा दिएको छु। साथै मिति २०७९/०५/२८ मा निर्वाचन आयोगसमक्ष काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा

दादा

daid38

स्पष्टता मागेको थिएँ। उक्त विषय मनोनयनपत्रमा स्पष्ट खुलाइएको र निर्वाचन अधिकृतले समेत रुजु गरी मनोनयनपत्र स्वीकृत गरिसकेपछि निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको अवस्थामा केही हसापछि मात्र मलाई अयोग्य ठहर गर्नु कानूनविपरीत र बदनियतपूर्ण छ।

कानून बमोजिम सिर्जना भएका व्यक्तिका जायज अपेक्षाहरूलाई संरक्षण गर्ने सिद्धान्त (legitimate expectation) न्यायिक अभ्यासमा स्थापित सिद्धान्त हो। "लाभको पद" को अवधारणाका सम्बन्धमा महेन्द्र बहादुर पाण्डे विरुद्ध श्री ५ को सरकार (फैसला मिति २०५०/४/७) को मुद्दामा सरकारी कोषबाट नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदलाई मात्र लाभको पद मानिने भनी व्याख्या गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको पद कुनै सरकारी सेवाको पद नभएको र नियमित पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त नहुने भएकाले यसलाई लाभको पद मान्न मिल्दैन।

अतः विपक्षी निर्वाचन आयोगले मिति २०७९/०७/१२ मा गरेको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७(२) ले प्रत्याभूत गरेको नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक तथा स्वच्छ व्यवहार प्राप्त गर्ने हकसमेतको विपरीत भएकाले सो निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, निर्देशन र कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ। साथै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा मैले दिएको उम्मेदवारी खारेज नगर्नु नगराउनु, मेरो उम्मेदवारी कायम राखी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी अन्तरिम आदेश र अग्राधिकारसमेत माग गर्दै पेस भएको डा. तोसिमा कार्कीको रिट निवेदन।

२. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट

daid38

दा. १०३९

निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्न।

यसमा निवेदक डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ४ बमोजिम मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भएको र निजले मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट अनुगमन गर्दा मिति २०७९।०९।०९ देखि मिति २०७९।०५।०२ सम्म भ्रमण भत्ता स्वरूप रु. १,३६,५००।- (एक लाख छत्तीस हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र) आर्थिक लाभ लिएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को देहाय खण्ड (घ) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मान्दै निज प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को देहाय (ड) मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन योग्यता पुरा गरेको नदेखिएको भनी सोही को दफा १५ को उपदफा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य ललितपुर, निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को निजको उम्मेदवारी अयोग्य कार्य गरी निर्वाचन आयोगले मिति २०७९।०७।१२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ।

निज निवेदक डा. तोसिमा कार्कीले आफू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको रूपमा रहेको, उक्त पदमा कुनै किसिमको सरकारी कोषको परिश्रमिक, आर्थिक सुविधा व्यवस्था नभएको तर बैठक भत्ताको व्यवस्था रहेको, आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार बन्न उक्त काउन्सिलको सदस्य लाभको पद हो वा होइन भनी निक्यौल गरी पाउन मिति २०७९।०५।२८ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको देखिन्छ। निजको विरुद्ध उक्त काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद भएको भनी परेको मिति २०७९।०७।०२ को उजूरीका सम्बन्धमा छानविन हुँदा मिति २०७९।०७।०७ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सोधनी गर्दा निज डा. तोसिमा कार्कीको पारिश्रमिक, सुविधा र भत्ता एवम् नेपाल सरकारले मेडिकल काउन्सिललाई आर्थिक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने नगराउने समेतका सम्बन्धमा उल्लेग गरेको देखिन्छ। उक्त सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०७९।०७।०८ को निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको जवाफमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा निजको कुनै मासिक तलब भत्ता नहुने तर बैठक भत्ता र अनुगमन

दा. १०३९

दाइडा

गर्दा अनुगमन भत्ता स्वरूप आर्थिक लाभ लिएको, उक्त काउन्सिललाई नेपाल सरकारले नियमित बजेटबाट अनुदान वा आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराएको भन्ने समेत व्यहोराको जवाफ रहेको देखिन्छ।

डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहेको पद प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) को प्रयोजनार्थ लाभको पदमा बहाल रहेको भन्न निजले उक्त काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद भएको वा नियमित जिम्मेवारीको पद भन्ने देखिन आउँदैन। कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिका नहुने अवस्थाको देखिन आउँछ। महेन्द्र बहादुर पाण्डे विरुद्ध निर्वाचन आयोग, बहादुर भवनसमेत भएको (ने.का.प. २०५० (ख) अंक ५, नि.नं. ४७३६) को रिट निवेदनमा "संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस कानूनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने" भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।

यसरी निवेदक डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहँदा नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ लिएको मात्र नमिल्ने देखिएको, निजले सो पद प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रयोजनार्थ लाभको पद हो होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन गर्दा कुनै जवाफ नपाएको, प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारको योग्यता तत् सम्बन्धमा विशेष कानूनले निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिभाषा समेतलाई निर्वाचन आयोगले आधार मानेको समेतका अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको उम्मेदवारीको सन्दर्भबाट निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति (irreparable damage)को स्थिति तथा सुविधाको सन्तुलन (balance of convenience) समेतको रोहबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक डा. तोसिमा कार्कीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ ललितपुरको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी निर्वाचन आयोग नेपालले मिति २०७९।०७।१२ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकको उम्मेदवारी खारेज नगर्नु, नगराउनु, निजको उम्मेदवारी समेतलाई

दाइडा

दाइ

यथावत कायम राखी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउनु भन्ने बेहोराको मिति २०७९।०७।१५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश।

३. प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निवेदक डा. तोसिमा कार्कीले मिति २०७९।६।२३ मा दर्ता नं. ६ बाट ललितपुर जिल्ला, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भई मनोनयनपत्र दर्ता गराउनु भएको थियो। सोही दिन मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गरिएको र मिति २०७९।६।२४ मा उम्मेदवारका विरुद्ध उजुरी दिने समय तोकिएको थियो। उक्त अवधिमा निवेदकविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेकोले मिति २०७९।६।२५ सम्म मनोनयनपत्र जाँच गर्दा पेश भएका कागजात, स्वघोषणा र वैयक्तिक विवरणका आधारमा उम्मेदवार हुन कानुनतः अयोग्य नदेखिएकोले मनोनयनपत्र स्वीकृत गरी उम्मेदवारको सूचीमा नाम समावेश गरिएको थियो। उम्मेदवारले नाम फिर्ता नलिएकोले मिति २०७९।६।२६ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको र सोही दिन सम्बन्धित राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको "गोलाकारभिन्न घण्टी" निर्वाचन चिन्ह निवेदकलाई प्रदान गरिएको थियो।

तर मिति २०७९।७।२ मा निवेदक नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा तथा भत्ता प्राप्त गरिरहेको हुँदा उक्त पदबाट राजीनामा नगरी उम्मेदवारी दर्ता गरेकोले लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति भएको भनी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १५(१)(ड), दफा १६(१)(ख) तथा दफा १७(१) बमोजिम संगीता बटाजुद्वारा उजुरी परेको थियो।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(२), निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ९(२) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १७(२) बमोजिम उम्मेदवारविरुद्ध दावी विरोधको समय समाप्त भएपछि प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण माग गर्न

दाइ

दावे

सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई मिति २०७९।७।३ मा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र दिइएको थियो। निवेदकले आफू लाभको पदमा बहाल नरहेको तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पद लाभको पद नभएको भनी स्पष्टीकरण पेस गरेपछि सो विषय मिति २०७९।७।६ मा निर्णयार्थ निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७९।७।१२ मा भएको निर्णय अनुसार निवेदकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको हैसियतले बैठक भत्ता तथा भ्रमण भत्ता समेत गरी रु. १,३६,५००/- प्राप्त गरेको देखिएकाले सार्वजनिक पद धारण गरेको तथा लाभको पदमा बहाल रहेको मानिएको छ। त्यस कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(ड) बमोजिम उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता पूरा नगरेको ठहर गरी सोही ऐनको दफा १५(५) बमोजिम निवेदकको उम्मेदवारी अयोग्य कायम हुने निर्णय भएको हो।

निवेदकले आफ्नो मौलिक हक, नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता वा कानुनी हक हनन भएको भनी दावी गरेको भए पनि यस कार्यालयको के कुन काम कारवाहीबाट त्यस्तो हक हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन। यस कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्राप्त कागजात, स्वघोषणा र कानुनी व्यवस्था बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मनोनयनपत्र स्वीकृत गरेको तथा पछि प्राप्त उजुरी सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अनुसार निर्वाचन आयोगमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको मात्र हो। त्यसैले यस कार्यालयको कुनै गैरकानूनी वा अधिकारविपरीत कार्य भएको नदेखिँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ।

यस कार्यालयबाट निवेदकको मौलिक हक, नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता वा कानुनी हक हनन भएको छैन। निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून, निर्वाचन आयोगको निर्देशन तथा सम्मानित अदालतबाट प्राप्त आदेश अनुसार स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा यस कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको छ। अतः यस कार्यालयको हकमा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी सादर निवेदन गर्दछु भन्ने बेहोराको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ललितपुर जिल्ला, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ।

दावे

Dr. D. S. M.

४. ललितपुर जिल्ला, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको र सो पदबाट राजीनामा नदिएँ उम्मेदवारी दिएको हुँदा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेकोले उम्मेदवारी खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको संगीता वटाजुको मिति २०७९/०७/०२ को उजुरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परेको र सो उजुरीउपर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट डा. तोसिमा कार्कीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाइएको थियो।

उक्त पत्रको जवाफमा डा. तोसिमा कार्कीले आफू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भएको, उक्त पद लाभको पद नभएको, निर्देशिकाअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई मात्र लाभको पद मानिने र मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद त्यस्तो पदभित्र नपर्ने जिकिर गर्दै स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको थियो। उजुरीको छानबिनका क्रममा आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरी डा. तोसिमा कार्की उक्त काउन्सिलको सदस्य हुन् वा होइनन् भए कहिलेदेखि र कुन प्रक्रियाबाट बहाल रहेकी हुन्, सदस्यले के कस्तो भत्ता वा सुविधा पाउँछन्, नेपाल सरकारले काउन्सिललाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ वा गराउँदैन तथा उक्त पद सार्वजनिक पद हो वा होइन भन्ने विवरण माग गरेको थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्राप्त जवाफअनुसार डा. तोसिमा कार्की मिति २०७८/०९/०२ देखि चार वर्षका लागि निर्वाचित सदस्यको रूपमा बहाल रहेको, मासिक तलबभत्ता नहुने तर बैठक भत्ता र अनुगमन/भ्रमण भत्ता उपलब्ध हुने, निजले आर्थिक लाभ लिएको, नेपाल सरकारले योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरेको र काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिने भन्ने जानकारी आयोगले पाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ड) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) अनुसार कुनै व्यक्ति उम्मेदवार हुन "कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको" हुनुपर्ने र सोही व्यवस्थाको

Dr. D. S. M.

दाइडा

स्पष्टीकरणअनुसार निर्वाचन वा मनोनयनबाट पूर्ति हुने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई "लाभको पद" मानिने हो। साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ तथा सम्बन्धित निर्देशिकाअनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि स्पष्टीकरण माग गर्ने, कागजात संकलन गर्ने, र आयोगले निर्णय गर्ने प्रक्रिया पूरा गरिएकोले डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ। "पारिश्रमिक" भन्नाले मासिक तलब मात्र नबुझी भत्ता वा अन्य आर्थिक सुविधा समेत बुझिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ३०६(छ) मा पारिश्रमिकको परिभाषामा तलब, भत्ता र अन्य किसिमका सुविधा समेत समावेश गरिएको हुँदा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यले बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता पाएको अवस्था "लाभको पद" को दायराभित्रै पर्छ।

डा. तोसिमा कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मिति २०७९/०१/०९ देखि २०७९/०५/०२ सम्म रु. १,३६,५००।- बराबरको बैठक तथा भ्रमण भत्ता लिएको देखिएकाले निजले आर्थिक सुविधा पाइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। काउन्सिल नियामक निकाय भएको, राज्यले योजना तथा कार्यक्रमका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने गरेको र सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो पदमा बहाल रहँदै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिनु स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मान्यतासँग मेल खाँदैन। निजले मनोनयनपत्र तथा स्वघोषणामा आफू लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी उल्लेख गरे पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्राप्त विवरणअनुसार बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता लिइरहेको देखिएकाले उक्त स्वघोषणा तथ्यसँग मेल खाएको समेत छैन।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद सार्वजनिक जवाफदेहीको पदसमेत भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रूपमा हेरिएको, सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्वसमेत रहेको र नियामक निकायको जिम्मेवार पदमा बहाल व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनु कानूनी मात्र नभई नैतिक प्रश्नसमेत हुन आउँछ। यसका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निर्वाचित भएपछि गरिएको शपथ, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी घोषणापत्र, तथा काउन्सिलअन्तर्गत विभिन्न समितिमा सदस्यको रूपमा तोकिएको कार्यजिम्मेवारीलाई

दाइडा

दा. दा. दा.

हेर्दा पनि यस्तो जिम्मेवार पदमा रहँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुनु उचित देखिँदैन।

डा. कमल भुसाल विरुद्ध निर्वाचन आयोग समेत भएको रिटमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै निर्वाह भत्ता लिइरहेको अवस्थालाई लाभको पदअन्तर्गत पर्ने व्याख्या भएको, निमा ग्याल्जेन शेर्पा विरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको मुद्दामा राज्य स्रोत वा सुविधा प्रयोग गर्ने पदमा बहाल व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने दृष्टिकोण स्वीकार गरिएको, डा. अमरेन्द्र यादव विरुद्ध डा. शिल्पा निराला कार्की समेत भएको मुद्दामा सम्बन्धित पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र उम्मेदवारीको प्रश्न सहज हुने आशयको आदेश भएको सन्दर्भमा पनि लाभको पदमा बहाल व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने मान्यता समर्थित भएको छ।

अतः डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित/कार्यकारी सदस्यको रूपमा बहाल रहेको, सो पदबाट बैठक भत्ता तथा भ्रमण भत्ता सहित आर्थिक सुविधा लिएको, सार्वजनिक जिम्मेवारी तथा नियामक भूमिकामा रहेको र यस्तो पदमा रहँदै उम्मेदवार हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व तथा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(ड) तथा दफा १५(५) बमोजिम निजको उम्मेदवारी अयोग्य कायम गर्ने आयोगको मिति २०७९/०७/१२ को निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको निर्वाचन आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखितजवाफ।

५. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम स्थापित काउन्सिल दफा ४ बमोजिम गठन हुने निकाय हो र सोही दफाको खण्ड (च) बमोजिम दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम आठ जना सदस्य निर्वाचित हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था तथा नियमावली, २०२४ को नियम २१६ बमोजिम डा. तोसिमा कार्की मिति २०७८/०९/०२ देखि चार वर्षको अवधिका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा बहाल हुनुहुन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल आधुनिक चिकित्साशास्त्रको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न तथा योग्य चिकित्सकहरूको दर्ता र नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सार्वजनिक निकाय हो। काउन्सिल ऐन,

दा. दा. दा.

आदेश

२०२० बमोजिम गठित काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले ऐनको दफा ११ तथा नियमावली, २०२४ बमोजिम गठित विभिन्न समितिहरूमा रही तोकिएको कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। काउन्सिल सार्वजनिक संस्था भएको हुँदा सो संस्थामा रहेका पदहरू सार्वजनिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित सार्वजनिक पदका रूपमा बुझिन्छ।

निर्वाचन आयोगबाट डा. तोसिमा कार्की काउन्सिलको सदस्य भए/नभएको, उक्त पदको प्रकृति, सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा काउन्सिलले ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था तथा उपलब्ध विवरण मात्र पठाएको र कुनै निर्णयात्मक राय व्यक्त गरेको छैन। त्यसैले काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई पूर्वाग्रही राय दिएको भन्ने रिट निवेदकको आरोपमा सत्यता छैन। "लाभको पद" को कानूनी व्याख्या गर्ने अधिकार आफ्नो नभई संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो। त्यसैले काउन्सिलका पदहरू लाभको पदभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा काउन्सिलले कुनै अन्तिम व्याख्या नगरेको र निर्वाचन आयोगले माग गरेको विवरण मात्र उपलब्ध गराएको हो।

साथै, डा. तोसिमा कार्कीले कार्यव्यस्तताको कारण नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदबाट मिति २०७९/०८/१८ मा राजीनामा पेश गर्नुभएको थियो। काउन्सिलको तर्फबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकारमा हस्तक्षेप वा हनन हुने कार्य नभएको हुँदा काउन्सिलको हकमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने मागदावी समेत रही नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखितजवाफ।

यस अदालतको आदेश

६. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०८१/०९/२७ गते सुनुवाई गरी आज निर्णय सुनाउने प्रयोजनार्थ पेस भएकोमा मिसिल सामेल रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ बेहोरासमेत अध्ययन गरी हेरियो।
७. रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री ललित बस्नेत तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री ओमप्रकाश अर्याल र श्री पुनदेवी महर्जनले दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुने काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक वा मासिक तलबभत्ता प्राप्त हुने पद नभएको; निजले उक्त

आदेश

दा. तोसिमा कार्की

पद लाभको पद हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता पाउन मिति २०७९।०५।२८ मा निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिएको भए पनि आयोगबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएको अवस्थामा मिति २०७९।०६।२३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गरेको र मनोनयनपत्र जाँचबुझ गरी उम्मेदवारी स्वीकृत भइसकेपछि मात्र मिति २०७९।०७।१२ मा निर्वाचन आयोगले निजले लाभको पद धारण गरेको भनी उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय न्यायोचित नरहेको; "लाभको पद" सम्बन्धी अवधारणाको व्याख्या गर्दा केवल प्राविधिक वा औपचारिक अर्थमा मात्र नहेरी उक्त पदबाट निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पक्षलाई समेत विचार गर्नुपर्ने भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो।

८. प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधीवक्ता श्री सुर्यराज दाहाल, उप-न्यायाधीवक्ता श्री अमित उप्रेती तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट उपस्थित बरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण खनालले रिट निवेदक डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम गठन भएको काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा बहाल रहेको र उक्त पद सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित पद भएको; काउन्सिलका सदस्यहरूले बैठक भत्ता तथा अनुगमनका क्रममा भ्रमण भत्ता जस्ता आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरेको र निवेदकले पनि सोही हैसियतमा आर्थिक लाभ लिएको देखिएकाले निज सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदमा बहाल रहेको मान्नुपर्ने; नेपालको संविधानको धारा ८७(१)(ड) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(ड) अनुसार "लाभको पद" मा बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र धारा ३०६(छ) अनुसार "पारिश्रमिक" मा भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा समेत समेटिने हुँदा बैठक तथा भ्रमण भत्तालाई समेत पारिश्रमिककै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने; विशेषतः स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी "लाभको पद" को अवधारणा केवल राजनीतिक पदमा सीमित नरही सरकारी कोषबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदसमेत समेट्ने व्यापक अवधारणा भएको हुँदा नियामकीय निकायको सदस्य जस्तो पदलाई पनि सोही दायराभित्र व्याख्या गर्नुपर्ने; उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेपछि तर परिणाम घोषणा नभइसकेको अवस्थामा योग्यतासम्बन्धी विवाद उठेमा सोको निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको धारा २४६(३)

दा. तोसिमा कार्की

Handwritten signature

तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई नै रहेको र आयोगले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी निवेदकको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरेको हुँदा उक्त निर्णय कानूनसम्मत भई रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने; प्रस्तुत विवाद संघीय संसद सदस्यको योग्यतासँग सम्बन्धित विषय भएकोले संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्नेसमेत जिकिर लिई बहस गर्नुभयो।

९. रिट निवेदन हेर्दा निवेदक डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट निर्वाचित सदस्यको रूपमा बहाल रहेको पदलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) को प्रयोजनार्थ "लाभको पद" अन्तर्गत पर्ने पद भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने, उक्त पदबाट नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त नहुने तथा केवल बैठकमा सहभागी हुँदा प्राप्त हुने बैठक भत्ता वा अनुगमनका क्रममा उपलब्ध हुने भ्रमण भत्ता जस्ता सीमित प्रकृतिका सुविधा मात्र उपलब्ध हुने भएकाले निवेदकलाई लाभको पदमा बहाल रहेको भनी उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गर्ने निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०७।१२ को निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उम्मेदवारी कायम राख्नुपर्ने भन्ने मागदावी रहेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोग तथा अन्य प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल सार्वजनिक प्रकृतिको नियामकीय निकाय भएको, काउन्सिलका सदस्यले बैठक भत्ता तथा भ्रमण भत्ता जस्ता आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरेको, संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ड) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) को व्यवस्था अनुसार सरकारी कोषबाट प्राप्त हुने भत्ता वा अन्य आर्थिक सुविधा समेत "पारिश्रमिक" को दायराभित्र पर्ने भएकाले निवेदक लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति मानिनुपर्ने र उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि संविधान तथा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर रहेको देखियो।

१०. उपर्युक्तानुसारको मागदावी र विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेतको रोहमा निवेदक डा. तोसिमा कार्की ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. ३

Handwritten signature

Handwritten signature

बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार रहेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम निर्वाचित सदस्यको रूपमा बहाल रहेको पदलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) को प्रयोजनार्थ "लाभको पद" (Office of Profit) अन्तर्गत पर्ने पद मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने नै प्रस्तुत विवादको मूल प्रश्न रहेको देखिन्छ। साथै, उक्त काउन्सिलको सदस्यको हैसियतमा प्राप्त हुने बैठक भत्ता वा अनुगमन/भ्रमण भत्ता जस्ता सुविधा संविधान र प्रचलित कानूनले उल्लेख गरेको "पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा" को दायराभित्र पर्ने हो वा होइन, तथा सो आधारमा निर्वाचन आयोगले मिति २०७९।०७।१२ मा निवेदकलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन? भन्ने प्रश्नहरूको निरूपण गरी निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने निक्कै गर्नुपर्ने देखिन आयो।

११. प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषयतर्फ प्रवेश गर्नुपूर्व प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत विवाद संघीय संसद सदस्यको अयोग्यतासँग सम्बन्धित रहेकोले नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी लिनुभएको जिकिरको निरूपण गर्नु उपयुक्त देखियो। यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) मा "उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ" भनी सोही उपधाराको खण्ड (ख) मा "संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता, सम्बन्धी विवाद" संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा संविधानको धारा २४६ को उपधारा (३) लाई समेत सामञ्जस्यपूर्वक हेर्नु आवश्यक देखिन्छ। सो उपधारामा "राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ" भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

Handwritten signature

दाइडा

१२. यसै प्रसङ्गमा निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३ का सम्बन्धित प्रावधानहरू पनि यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छन्। सो ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा “सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी परिच्छेद-१० बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।^१ सोही दफाको उपदफा (२) मा “सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन बाहेक अन्य निर्वाचन सम्बन्धी परिच्छेद १० बमोजिमको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतले गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। यसैगरी, ऐ. उपदफा (३) मा सो ऐन अन्तर्गतका केही कसूरमा^२ “...सजाय हुने कसूर तथा त्यस्तो कसूरको उद्योग, मदत वा दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ।

१३. त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा रहेका सम्बन्धित प्रावधानहरू पनि यस सन्दर्भमा स्मरणीय देखिन्छन्। सो ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा “अदालत भन्नाले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। ऐ. दफा १२ मा “उम्मेदवारको योग्यता” तथा दफा १३ मा “उम्मेदवारको अयोग्यता” का आधारहरू किटान गरिएको देखिन्छ भने “उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने” व्यवस्था रहेको दफा १५ को उपदफा (१) ले “सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. उपदफा (५) मा “आयोगले ... निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय

दाइडा

^१ सो ऐनको परिच्छेद १० मा निर्वाचन बढेर सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै दफा ४३ मा निर्वाचन बढेर गर्न उजुर दिन सक्ने; दफा ४४ मा दोहोर्न्याई मतगणना हुन सक्ने जस्ता प्रावधानहरू रहेको देखिन्छ।

^२ उक्त निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (३) मा ऐ. ऐनका दफा ४ को उपदफा (५) र (६), दफा ५ को उपदफा (५), दफा ६ को उपदफा (३), दफा १२ को उपदफा (२), दफा १४ को उपदफा (२), दफा १६ को उपदफा (२), दफा १८ को उपदफा (२) दफा २० को उपदफा (३) र (४), दफा २१ को उपदफा (२), दफा २२ को उपदफा (२) तथा दफा २३ को उपदफा (२) लाई सो उपदफाको प्रयोजनको लागि तोकिएको देखिन्छ।

Amidol

गरिसक्नु पर्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। साथै, "पद मुक्त हुने" सम्बन्धि व्यवस्था रहेको ऐ. दफा १६ को उपदफा (१) मा "सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

१४. उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरूको निरूपणका लागि विधायिकाले निर्वाचन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा फरक-फरक निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ। उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि तर निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुअघि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यस उपर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको धारा २४६ को उपधारा (३) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम "निर्वाचन आयोग" लाई प्रदान गरिएको देखिन्छ। निर्वाचन सम्पन्न भई व्यक्ति संसद सदस्यको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको अयोग्यताको प्रश्न उठेमा सो विषयको निरूपण नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २(क) तथा दफा १६ बमोजिम "संवैधानिक इजलास" बाट हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसरी उम्मेदवारको अयोग्यताको प्रश्न र निर्वाचित सदस्यको अयोग्यताको प्रश्नलाई विधायिकाले पृथक् रूपमा नियमन गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा उठ्ने विवादहरूको निरूपणका लागि फरक-फरक निकायहरू तोकेको विधायिकी संरचनाबाट स्पष्ट देखिन्छ। साथै, निर्वाचनसम्बन्धी कसूरमा निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३ ले माथि विवेचना गरिएबमोजिम संवैधानिक इजलास वा उच्च अदालत वा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले कारबाही र किनारा गर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ।

१५. प्रस्तुत विवाद उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेको विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ, जसउपर निर्णय गर्ने अधिकार माथि विवेचना गरिए अनुसार नेपालको संविधानको धारा २४६(३) र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई नै प्रदान गरिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले सोही कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै निवेदकको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयको न्यायिक

Amidol

दस्तावेज

परीक्षण प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा कानूनको वैधतामाथि प्रश्न उठेको नभई निर्वाचन आयोगको निर्णयको वैधता परीक्षणको प्रश्न मात्र उपस्थित भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा गरेको निर्णय सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत संयुक्त इजलासबाट परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन आएन।

१६. अब, विवादको मूल प्रश्नको रूपमा रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम निर्वाचित सदस्यको रूपमा बहाल रहेको पदलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ड) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) को प्रयोजनार्थ "लाभको पद" (Office of Profit) अन्तर्गत पर्ने पद मात्र मिल्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्न वाञ्छनीय हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ड) मा "कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको" व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाको स्पष्टीकरणमा "लाभको पद" भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३०६ को खण्ड (छ) मा रहेको "पारिश्रमिक" को परिभाषालाई आधार बनाई बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्तासमेत "पारिश्रमिक" को दायराभित्र पर्ने र सो आधारमा निवेदक "लाभको पद" मा बहाल रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ। सोतर्फ हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३०६ मा रहेको "परिभाषा र व्याख्या" सामान्य परिभाषा हो र यसले संविधानमा प्रयुक्त शब्दहरूको सामान्य अर्थको स्पष्टता प्रकट गर्दछ। तर धारा ८७(१)(ड) को स्पष्टीकरण खण्डले "लाभको पद" को अर्थलाई आफैमा विशेष र किटानी रूपमा "निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद" भनी परिभाषित गरेको छ। कानून व्याख्याको स्थापित सिद्धान्त "generalia specialibus non derogant" अनुसार जहाँ सामान्य व्यवस्था र विशेष व्यवस्थाबीच अन्यौलता उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ विशेष व्यवस्थाले सामान्य व्यवस्थालाई निर्देश गर्दछ। यस आलोकमा धारा ३०६(छ) मा रहेको सामान्य परिभाषाले धारा ८७(१)(ड)

दस्तावेज

Amid

को स्पष्टीकरणद्वारा निर्दिष्ट गरिएको विशेष मापदण्डलाई विस्थापित गर्न सक्दैन। "लाभको पद" को संवैधानिक अर्थ निर्धारण गर्दा धारा ३०६ को खण्ड (छ) को सामान्य परिभाषात्मक व्यवस्थाभन्दा धारा ८७(१)(ड) को स्पष्टीकरणमा निर्दिष्ट विशेष मापदण्ड नै प्राथमिक मार्गदर्शक हुने हुन्छ।

१७. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) मा समेत प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुनका लागि कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोही दफाको स्पष्टीकरणमा पनि "लाभको पद" सम्बन्धी संवैधानिक स्पष्टतालाई यथावत् अनुसरण गरिएको देखिन्छ। ऐ. ऐनको दफा १३ मा रहेको "उम्मेदवारको अयोग्यता" को खण्ड (क) ले दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। उपरोक्तानुसारका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले "लाभको पद" सम्बन्धी प्रावधान निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने एउटा वैधानिक उपकरणका रूपमा रहेको देखिन्छ। यस प्रावधानको अभिप्राय राज्यको स्रोत, शक्ति वा प्रभावमा पहुँच राख्ने व्यक्तिले निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित लाभ उठाउन नपाओस् भन्ने नै हुन आउँछ। यस रोहमा, "लाभको पद" सम्बन्धी प्रावधान पदको औपचारिक नामकरण वा संस्थागत वर्गीकरणका आधारमा अयोग्यता आरोपित गर्ने उपकरण नभई राज्यसँगको आर्थिक निर्भरता वा पदीय प्रभावमार्फत निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित लाभ लिने सम्भावना रोक्ने संवैधानिक संयन्त्र रहको देखिन्छ।

१८. उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको समष्टिगत अध्ययन गर्दा "लाभको पद" को अवधारणाभित्र पर्नका लागि सम्बन्धित पद सरकारी कोषसँग आर्थिक रूपमा आवद्ध हुनुपर्ने; सो पदबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त हुनुपर्ने; र त्यस्तो आर्थिक लाभ पदमा बहाल रहँदा नियमित र स्थायी रूपमा प्राप्त हुने प्रकृतिको हुनुपर्ने जस्ता तत्त्वहरू सँगसँगै स्थापित नभएसम्म कुनै पदलाई "लाभको पद" मान्न पर्याप्त आधार पुग्ने समेत देखिँदैन।

१९. "लाभको पद" सम्बन्धी अवधारणाको व्याख्या गर्ने क्रममा यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तहरू समेत सान्दर्भिक देखिन्छन्। महेन्द्र बहादुर पाण्डे विरुद्ध निर्वाचन

Amid

Handwritten signature

आयोगसमेत भएको मुद्दा^१ मा यस अदालतको ५ सदस्यीय विशेष इजलासले बहुमतको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७(१)(ड) असंवैधानिक नभएको ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ। तथापि, उक्त मुद्दाको प्र.नं. १४ मा इजलासले "लाभको पद" को संवैधानिक प्रयोजन स्पष्ट पाउँ पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको पदीय कर्तव्यसँग संसदीय कर्तव्यको तालमेल नबस्ने र आर्थिक लाभका कारण प्रभाव वा दबाबमा पर्न सक्ने अवस्था रोक्नु नै यस प्रावधानको मूल उद्देश्य हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस आधारमा हेर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको पद, जसबाट नियमित पारिश्रमिक प्राप्त हुँदैन, जसमा निवेदकको स्थायी आर्थिक निर्भरता छैन र सो पदमा रहने पदाधिकारीले संस्थाको पदसोपानमा रही कार्यकारीको हैसियतमा कार्य समेत गर्दैन, त्यस्तो पदधारकले पदीय प्रभाव वा दबाबमा परी निर्वाचनमा अनुचित लाभ लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने देखिँदैन। यसर्थ उक्त मुद्दाको निर्णयाधार (ratio decidendi) प्रस्तुत विवादमा सिधै लागू हुने देखिँदैन। अझै, उल्लेखनीय के छ भने उक्त मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालले आफ्नो अल्पमत रायमा संविधानको स्पष्टीकरण खण्डले "लाभको पद" को दायरा निश्चित र सीमित गरिसकेको अवस्थामा ऐनले सो दायरा बाहिर गई अयोग्यताको सीमा फराकिलो पार्न मिल्दैन, किनभने त्यसो गर्नाले नागरिकको निर्वाचनमा सहभागिताको स्वतन्त्रताको दायरा साँघुन्याउने परिणाम हुन्छ भनी महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारसमेत तय गर्नुभएको देखिन्छ। यो राय अल्पमतमा परेतापनि यसमा विवेचित "संविधानको स्पष्टीकरण खण्डले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गई अयोग्यता विस्तार गर्न नमिल्ने" भन्ने सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा पनि सान्दर्भिक र विचारणीय नै रहने देखिन्छ।

२०. यसैगरी, प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगले आफ्नो लिखित जवाफमा डा. कमल भुसाल (०७९-WO-०३७३), निमा ग्याल्जेन शेर्पा (०७८-WO-१०६८) र डा. अमरेन्द्र यादव (०७८-WO-१२९०) का मुद्दाहरू उद्धृत गरी लाभको पदमा बहाल व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने मान्यता पुष्टि भएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ। तर ती मुद्दाहरूको तथ्यगत आधार प्रस्तुत विवादसँग भिन्न रहेकाले ती नजिरहरूबाट प्रतिपादित सिद्धान्त यहाँ सिधै लागू हुने अवस्था भने देखिँदैन। डा. कमल भुसालको मुद्दामा निवेदकले सरकारी कोषको मासिक

Handwritten signature

^१ ने.का.प. २०५० (ख) अंक ५, नि.नं. ४७३६

द्वितीय

निर्वाहभत्ता तथा छात्रवृत्ति बुझी काम र अध्ययन गर्न कबुलियत गरेको अवस्था रहेको, अर्थात् राज्यको कोषबाट नियमित मासिक आर्थिक लाभ प्राप्त भएको अवस्था विद्यमान थियो। त्यस मुद्दामा "लाभको पद" को मापदण्डका आवश्यक तत्त्वहरू; नियमित आर्थिक लाभ र राज्यसँगको प्रत्यक्ष आर्थिक निर्भरता स्पष्ट रूपमा स्थापित रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यले नियमित मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था नभएको र राज्यप्रति कुनै कबुलियत वा कर्तव्यगत बाध्यता नभएको तथा बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता विशेष कार्यमा सहभागी हुँदा मात्र उपलब्ध हुने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ। यी दुई मुद्दाका तथ्यगत परिस्थिति तात्त्विक रूपमा भिन्न भएकाले डा. कमल भुसालको मुद्दाको ठहर यस विवादमा लागू हुने देखिँदैन।

२१. यस्तै, निमा ग्याल्जेन शेर्पाको मुद्दामा विवादको विषय स्थानीय तहको बहालवाला निर्वाचित पदाधिकारीको उम्मेदवारी सम्बन्धी रहेकोमा उक्त मुद्दामा यस अदालतले स्थानीय तहको पदाधिकारीले पदमा बहाल रहँदा स्थानीय तहको बजेट, साधन र स्रोतमा पहुँच हुने र सो आधारमा मतदातालाई अदृश्य रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहने भएकाले त्यस्तो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिताको व्यवस्था संविधान र कानून विपरित नभएको ठहर गरेको देखिन्छ। उक्त मुद्दाको आधारको रूपमा रहेको स्थानीय तहको राजकीय साधन र स्रोतमा प्रत्यक्ष पहुँच र सोबाट निर्वाचनमा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने ठोस सम्भावना प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान छैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यले राज्यको बजेट, साधन वा स्रोतमा कुनै नियन्त्रण वा पहुँच राख्ने नदेखिएको र सो पदको धारणले मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै अवस्था सिर्जना भएको पनि देखिँदैन। यसरी ती दुई मुद्दाको मूल तथ्यगत आधार र "लाभको पद" सम्बन्धी प्रश्नको प्रकृति नै प्रस्तुत विवादभन्दा भिन्न रहेकाले उक्त व्याख्याले प्रस्तुत सन्दर्भमा बाध्यात्मक प्रभाव (binding force) राख्ने देखिँदैन। डा. अमरेन्द्र यादवको मुद्दामा पदबाट राजीनामा दिएपछि उम्मेदवारीको प्रश्न सहज हुने आशयको आदेश भएको उल्लेख गरिएको, तर त्यसले उक्त पद "लाभको पद" नै हो भनी अन्तिम रूपमा ठहर गरेको अवस्था नभई एउटा अन्तरिम प्रकृतिको आदेश रहेको देखिन्छ। न्यायिक नजिरको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि अदालतको निर्णयाधार (ratio decidendi) स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्तरिम आदेशमा व्यक्त गरिएको आशय मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसरी हेर्दा प्रत्यर्थीले उद्धृत गरेका मुद्दाहरू प्रस्तुत

द्वितीय

दस्तावेज

विवादसँग तथ्यगत र कानूनी रूपमा समानान्तर नरहेको र ती मुद्दाहरूबाट प्रतिपादित सिद्धान्त यस विवादमा सिधै लागू हुने अवस्था नदेखिँदा ती नजिरहरूले निवेदकको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई समर्थन गर्न पर्याप्त भएको देखिएन।

२२. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा हेर्दा पनि कार्यपालिकासँग आर्थिक सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले व्यवस्थापिकामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न नहोस् तथा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहोस् भन्ने उद्देश्यले "Office of Profit" को अवधारणा बेलायती संवैधानिक परम्परामा ऐतिहासिक रूपमा विकसित भएको पाइन्छ।^४ यसै परम्पराबाट प्रेरित भई भारतको संविधानमा समेत [२१६] "Office of Profit" सम्बन्धी अयोग्यताको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Guru Gobinda Basu^७ को मुद्दामा "Office of Profit" को परीक्षण गर्दा पदमा सरकारको नियन्त्रण, नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने अधिकार, पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभको स्वरूप तथा पदको कार्यप्रकृति जस्ता पक्षहरूको समग्र परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी Shivamurthy Swami^८ को मुद्दामा पनि कुनै पद "Office of Profit" हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्दा पदबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ, पदमा सरकारको नियन्त्रण तथा पदको वास्तविक कार्यप्रकृतिलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट गरिएको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा Jaya Bachchan^९ को मुद्दामा पदको औपचारिक नामकरण वा संस्थाको वर्गीकरण मात्र निर्णायक आधार नहुने, बरु उक्त पदबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको स्वरूप तथा सरकारसँगको सम्बन्धको प्रकृति समेतलाई समग्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट गरेको देखिन्छ।

दस्तावेज

^४ यस सन्दर्भमा Act of Settlement 1701 तथा पछि विकसित House of Commons Disqualification Act 1975, उल्लेखनीय देखिन्छ।

^५ 102. Disqualifications for membership (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament - (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;

^६ 191. Disqualifications for membership (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;

^७ Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad Ghosal, AIR 1964 SC 254

^८ Shivamurthy Swami v. Agadi Sanganna, AIR 1971 SC 1538

^९ Jaya Bachchan v. Union of India, AIR 2006 SC 2119

Dr. D. D. S.

२३. प्रस्तुत विवादमा निवेदक डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको रूपमा बहाल रहेको पदको प्रकृति के कस्तो हो भन्ने परीक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम चिकित्साशास्त्रको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न तथा योग्य चिकित्सकहरूको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थापना गरिएको देखिन्छ। सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (च) बमोजिम दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सकहरू काउन्सिलको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। काउन्सिलका सदस्यहरूले नियमनसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यक समितिहरूमा रही काउन्सिलको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको पाइनुका साथै मिसिलसामेल कागजात तथा सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत भएको बहसजिकिरबाट काउन्सिलका सदस्यलाई नियमित मासिक पारिश्रमिक वा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था नरहेको र बैठकमा सहभागी हुँदा दिइने बैठक भत्ता वा अनुगमन कार्यमा संलग्न हुँदा उपलब्ध गराइने भ्रमण भत्ता मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ।

२४. प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगले निवेदकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट रु. १,३६,५००/- प्राप्त गरेको तथ्यलाई "आर्थिक सुविधा पाएको" भन्ने प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। तर उक्त रकमको प्रकृतिको परीक्षण गर्दा सो रकम मिति २०७९।०१।०९ देखि मिति २०७९।०५।०२ सम्म करिब चार महिनाको अवधिमा भ्रमण भत्ताको रूपमा प्राप्त भएको भन्ने निवेदन दावीलाई खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन। स्वयं नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले समेत काउन्सिलका निर्वाचित सदस्य वा पदेन सदस्यलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नहुने र बैठक भत्ता वा अनुगमन/भ्रमण भत्ता उपलब्ध हुने भनी बहस गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त रकम पारिश्रमिकका रूपमा नभई बैठकमा उपस्थित भएवापत तथा अनुगमन कार्यमा संलग्न भएवापत निवेदकले प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ।

२५. अब, निर्वाचन आयोगले मिति २०७९।०७।१२ मा गरेको निर्णयको सम्बन्धमा हेर्दा, मिसिलसंलग्न कागजातबाट देखिएअनुसार आयोगले निवेदक डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको, सो पदमा रहँदा बैठक भत्ता तथा अनुगमन भत्ता जस्ता आर्थिक सुविधा प्राप्त गरेको तथा उक्त पद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान

Dr. D. D. S.

दाइ

आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को देहाय खण्ड (घ) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिने आधारमा निज लाभको पदमा बहाल रहेको निष्कर्ष निकाली उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरेको निर्णयमा सारवान र कार्यविधिगत त्रुटिहरू रहे नरहेको भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो।

२६. सारवान व्यवस्थातर्फ हेर्दा निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को "सार्वजनिक पद" सम्बन्धी परिभाषालाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को "लाभको पद" को परीक्षणको आधार बनाएको देखिन्छ। यी दुई भिन्न ऐनका दुई भिन्न प्रयोजनका परिभाषाहरू हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि बनाइएको विशेष कानून हो। त्यस ऐनमा "सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति" को परिभाषा व्यापक राखिनुको कारण भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो पारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो। यो उद्देश्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गर्ने उद्देश्यभन्दा मौलिक रूपमा भिन्न रहन्छ। कानून व्याख्याको स्थापित सिद्धान्त "*in pari materia*" अनुसार एउटा विषयसँग सम्बन्धित भिन्न भिन्न कानूनहरू रहेको भएमा तिनीहरूलाई एउटै कानून जस्तो मानेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ पृथक प्रयोजनको ऐनमा रहेको परिभाषा स्वतः आयात गर्न मिल्दैन। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने योग्यताको प्रश्न संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ड) र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) ले नै नियन्त्रण गर्दछ। ती व्यवस्थाहरूले "लाभको पद" को अर्थ आफैँमा किटानी गरिसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनको परिभाषा समावेश गरी निर्णय गर्नु त्रुटीपूर्ण देखिन्छ। यसर्थ आयोगले अमिल्दो कानूनी मापदण्ड अवलम्बन गरी निवेदकलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने निर्णय गरेको देखिन्छ।

२७. कार्यविधिगत व्यवस्थातर्फ हेर्दा प्रशासकीय कानूनको वैध अपेक्षाको सिद्धान्त (doctrine of legitimate expectation) प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रासङ्गिक देखिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार जब कुनै सार्वजनिक निकायले आफ्नो आचरण, मौनता वा पूर्व व्यवहारद्वारा व्यक्तिमा कुनै जायज अपेक्षा सिर्जना गर्छ भने सो निकायले त्यस अपेक्षा विपरीत पर्याप्त सूचना र उचित

दाइ

And...

सुनुवाइ बिना निर्णय गर्न पाउँदैन। यस सिद्धान्तलाई Council of Civil Service Unions¹⁰ को मुद्दामा Lord Fraser ले प्रतिपादन गर्नुभएकोमा यस अदालतले पनि सुरेन्द्र बहादुर विष्ट विरुद्ध नेपाल सरकार¹¹ समेतका मुद्दाहरुमा यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ।

२८. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थातर्फ हेर्दा, निवेदकले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै मिति २०७९।०५।२८ मा निर्वाचन आयोगसमक्ष काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद हो वा होइन भनी स्पष्टता माग गरेको देखिन्छ। आयोगले उक्त निवेदनमा कुनै जवाफ नदिई मौन रहेको; त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र रुजु गरी उम्मेदवारी स्वीकृत गरेको; अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको र निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेको देखिन्छ। यी सबै कार्यबाट निवेदकमा आफ्नो उम्मेदवारी वैध र कानूनसम्मत छ भन्ने जायज अपेक्षा (Legitimate Expectation) सिर्जना भएको र यस अवस्थाले निवेदकमा आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहने वैध अपेक्षा उत्पन्न गरेको देखिन्छ। निर्वाचन प्रचारप्रसार सुरु भइसकेपछि कुनै नयाँ तथ्य वा परिस्थितिको उदय नभई केवल तेस्रो पक्षको उजुरीका आधारमा एकाएक उम्मेदवारी खारेज गर्नु उक्त जायज अपेक्षासमेतको उल्लङ्घन हुन जान्छ। आयोगले आफ्नो मौनताद्वारा सिर्जना गरेको अपेक्षा विपरीत कार्य गर्नु प्रशासकीय कानूनको दृष्टिले समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन। यदि आयोगले उम्मेदवारी दर्ताअघि नै निवेदकको प्रश्नको उत्तर दिई काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद हो भनी स्पष्ट पारेको भए निवेदकले अर्कै निर्णय लिन सक्नेमा सो अवसर प्रदान नगरी उम्मेदवारी स्वीकृत भइसकेपछि मात्र अयोग्य ठहर गर्नु न्यायको रोहमा उचित देखिन आएन।

२९. यस्तै, निवेदकले रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०७।१२ को निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) द्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको हक तथा धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकसमेतको उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको सन्दर्भमा, नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको देखिन्छ। यो स्वतन्त्रतासँगै मतदान गर्ने अधिकार, निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार र निर्वाचित हुने अधिकार (Right to be Elected) जोडिएर आउने निर्विवाद छ। यो स्वतन्त्रता कानूनद्वारा

And...

¹⁰ Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374

¹¹ ने.का.प. २०७४, नि.नं. ९८३८

And

संविधानसम्मत् उद्देश्यका लागि मात्र प्रतिबन्धित गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा निर्वाचन आयोगले "लाभको पद" को परिभाषाका लागि जुन कानूनी मापदण्ड अवलम्बन गरी निवेदकको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरेको छ, सो मापदण्ड माथि विवेचना गरिए बमोजिम संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ड) को स्पष्टीकरण तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) ले निर्दिष्ट गरेको विशेष परिभाषासँग सुसङ्गत नरहेको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को भिन्न प्रयोजनका लागि निर्मित परिभाषालाई टेको लगाई निर्णय गरेको देखिन्छ। कानूनसम्मत् मापदण्डको प्रयोग नगरी कुनै नागरिकको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकारमा अवरोध उत्पन्न गरिनु धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुन जाने देखिन्छ। साथै, नेपालको संविधानको धारा १८ ले कानूनको समान संरक्षणको हक प्रत्याभूत गरेको छ। निवेदकले उम्मेदवारी दर्ताअघि नै काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद हो वा होइन भनी स्पष्टता मागेकोमा निर्वाचन आयोगले मौन रही मनोनयनपत्र स्वीकृत गरेको र निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको अवस्थामा पछि पर्याप्त सूचना तथा उचित सुनुवाइको अवसर बिना नै एकतर्फी रूपमा उम्मेदवारी खारेज गर्नुले नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रत्याभूत निष्पक्ष कारबाही र स्वच्छ व्यवहार पाउने हकको समेत उल्लङ्घन भएको मान्नुपर्ने देखिन आउँछ।

३०. उपरोक्त विवेचित तथ्य, सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त तथा तुलनात्मक न्यायशास्त्रका मापदण्डहरूको समष्टिगत मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदबाट नियमित मासिक पारिश्रमिक वा स्थायी आर्थिक लाभ प्राप्त हुने व्यवस्था अभिलेखबाट स्थापित भएको नदेखिएको तथा बैठक भत्ता वा अनुगमन/भ्रमण भत्ता जस्तो प्रकृतिको देखिएको अवस्थामा उक्त पदलाई "सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पद" को संवैधानिक मापदण्डभित्र राख्न मिल्ने देखिँदैन। "लाभको पद" लाई प्रयोजनमूलक व्याख्याको सानिध्यमा हेर्दा पनि राज्यको स्रोत, शक्ति वा प्रभावमा पहुँच राखी निर्वाचनमा अनुचित लाभ उठाउन सक्ने सम्मको अवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको हकमा विद्यमान देखिँदैन। साथै, निवेदकले उम्मेदवारी दर्ताअघि नै स्पष्टता मागेकोमा आयोग मौन रहेको र मनोनयनपत्र स्वीकृत भई निर्वाचन चिन्ह प्रदान

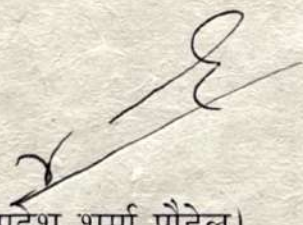
And

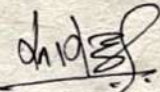
dm

भइसकेपछि मात्र उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्नु वैध अपेक्षाको सिद्धान्त र आयोगको आफ्नै संस्थागत आचरणसँग असङ्गत देखिनुका साथै निर्वाचन आयोगको यसप्रकारको कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता तथा समानताको हकमा अनुचित प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखियो।

३१. अतः निवेदकलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) बमोजिम लाभको पदमा बहाल रहेको भनी ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्ने गरी निर्वाचन आयोग नेपालले मिति २०७९।०७।१२ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०७९।०७।१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले नै निज निवेदकको उम्मेदवारी कायम भई निर्वाचित समेत भैसकेको सन्दर्भमा थप केही बोलिरहनु परेन। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु।

उक्त रायमा सहमत छु।


(महेश शर्मा पौडेल)
न्यायाधीश


(मनोजकुमार शर्मा)
न्यायाधीश

आदेशको मस्यौदा तयार गर्ने: उपसचिव राजेन्द्र पौडेल

इजलास अधिकृत:- संगीता के.सी.

कम्प्युटर अपरेटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८१ साल फागुन २७ गते रोजु ३ शुभम् ----- ।